

1500024-89.2022.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... informa que a equipe, já ciente do intenso tráfico de drogas no trailler do Reginho, foram para o vale do Redentor e em local estratégico avistaram o réu entregando objetos a transeuntes. Registraram uma imagem. O réu é um adolescente, conhecido dos meios policiais, não se recorda o nome, mas está nos autos. Eles se revezavam para o tráfico de drogas. O adolescente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500024-89.2022.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500024-89.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2006841/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 22336077 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 14/22/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2006841 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 14/22/200 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO AURÉLIO DA SILVA BALESTRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Marco Aurélio da Silva Balestra, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, eis que no dia 07 de janeiro

de 2022, por volta das 19h20min, na Rua Otávio Cury, altura do nº 10, Vale do Redentor IV, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo 11 (onze) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 15,39 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 66/67 veio acompanhada do Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de páginas 01/64.

Prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme decisão de págs. 42/43.

O réu foi notificado (págs. 84) e apresentou defesa preliminar (págs. 85/86), sustentando que no decorrer da instrução provará sua inocência, bem como pela juntada posterior de todos os meios de prova admitidos em direito. Requer a improcedência da ação. Apresentou rol de testemunhas.

A denúncia foi recebida aos 04 de fevereiro de 2022, determinando-se a citação do réu e designando audiência de instrução, debates e julgamento (pág. 88/91).

Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, por ordem da Instância Superior - págs. 130/156;

Expediu-se alvará de soltura - págs. 167/170.

Durante a solenidade de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ - pg. 176/178.

Na fase do art. 402 do CPP foi requerida a juntada de vídeo sobre o contexto de traficância - pg. 178.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal destacando a confissão do réu. Extraiu imagens do vídeo apresentado pela polícia militar, concluindo que há provas suficientes para a condenação. Sugere a pena base mínima e observância da confissão, porém não pode ser beneficiado com a minorante diante do passado infracional, recebendo o regime fechado - pgs. 182/186.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se nas pgs. 190/198 alegando que a condenação depende de um juízo de certeza, devendo o réu ser beneficiado pela dúvida. Ressalta a confissão do réu, porém indica sua primariedade, de modo que ele não faz do tráfico seu meio de vida. Pondera que a questão do réu é muito mais de dependência química e, portanto, social do que criminal. Alega inexistência do dolo de traficância, o que deve conduzir à absolvição do réu. Em caso de condenação, pugna pela fixação da pena mínima, devendo ser beneficiado pelo regime aberto, permanecendo em liberdade para que assim possa recorrer.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 08), auto de constatação preliminar (págs. 12) e pelos laudos periciais de páginas 110/112.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Felipe Garcia Braga informa que o local é muito conhecido por tráfico de drogas, o "trailler do Reginho". Por haver traficantes e usuários que passam por ali, em breve monitoramento posicionaram-se no local e em movimentação visualizaram o réu Marco Aurélio junto com o adolescente João Marcelo. Percebeu que ele atendia usuários, ia atrás do trailler do Reginho e entregava algo. Fez uma filmagem dos fatos e passou para o assistente de Promotoria, Nilton. Convictos de que o réu estava traficando partiram para a abordagem fez busca pessoal e encontrou os eppendorfs de cocaína. Ele não era conhecido dos meios policiais e não viu ele mais em atitudes suspeitas. O réu negou a propriedade das drogas.

Tiago Policcici de Oliveira informa que a equipe, já ciente do intenso tráfico de drogas no trailler do Reginho, foram para o vale do Redentor e em local estratégico avistaram o réu entregando objetos a transeuntes. Registraram uma imagem. O réu e um adolescente, conhecido dos meios policiais, não se recorda o nome, mas está nos autos. Eles se revezavam para o tráfico de drogas. O adolescente empreendeu fuga. O réu foi abordado. O depoente havia avistado o réu naqueles locais, mas nunca o abordou. Após o réu ser colocado em liberdade não o viu em locais incompatíveis. Confirma que possui a imagem da traficância.

Marco Aurélio da Silva Balestra, interrogado, informou que tem duas passagens de menor por prática de tráfico. Ficou na fundação casa por tráfico. Estava em liberdade desde 2020. Tem 20 anos atualmente. Trabalha na roça. Mora com sua mãe, mas ela lhe mandou embora e foi morar com a esposa. Tem 1 filho de 7 meses. Usa maconha e cocaína. Cocaína só antes. Confirma a versão dos policiais. Arrepende-se. Foi abordado e acharam a droga. Tem filho para criar. Não conhecia o adolescente. Não tinha vendido drogas naquele dia. Tinha acabado de começar. Havia apenas as 11 porções de droga que foram apreendidas. Reafirma que se arrepende e vai buscar melhora. Gostaria de uma oportunidade e agradece.

2-) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL:

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois "goza de presunção de credibilidade".

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

Como se nota no caso concreto, a versão dos policiais veio cancelada pela confissão do réu que admitiu a prática da traficância nas circunstâncias de tempo e local indicadas na denúncia.

Destarte, não há campo para desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco para absolvição do réu.

A tese defensiva de ausência de dolo é insustentável, pois extrai-se do interrogatório que o réu tinha plena consciência do que fazia e do caráter ilícito de sua conduta. Não se pode cogitar que tenha se dirigido a ponto de venda de drogas e ali permanecido para entrega de drogas a terceiro sem que sua conduta

estivesse diretamente direcionada ao injusto tipificado na fattispecie do art. 33 da Lei de Drogas.

Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 66/67, para CONDENAR MARCO AURÉLIO DA SILVA BALESTRA pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

No entanto, o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas (neste caso não é suficiente para gerar acréscimo na pena, pois a apreensão foi de cerca de 3,93 gramas – conforme massa líquida, verificada em laudo pericial de pág. 110/112).

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo não encontra campo para acréscimo, uma vez que a quantidade apreendida está dentro dos padrões das apreensões normais e corriqueiras nesta comarca, ao passo que não há diversidade de drogas, mas apenas uma substância apreendida.

O motivo do delito se constitui pela vontade de locupletar-se com a venda de entorpecente o que já está albergado no próprio tipo legal.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base da pena privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 1/6 em 05 (cinco) anos e 500 dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes. Em que pese a confissão, o réu recebeu pena mínima na primeira etapa e a atenuante não pode conduzir a sanção a quem do mínimo legal, conforme súmula 231 do E. STJ. Pelo mesmo motivo, inócuo a atenuante da menoridade relativa (réu nascido aos 04.01.2002).

O réu não faz jus à minorante, pois ostenta passado infracional documentado na certidão de pgs. 22 e pelo próprio depoimento do réu que alega ter sido internado por prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Não se pode perder de vista que somente é ato infracional aquilo previsto como crime. Diz o artigo 103 da Lei 8.069/1990: "Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal." (destaque do Juízo).

Assim, a conduta praticada pelo réu enquanto menor tem natureza criminosa (prevista como crime), porém recebe o tratamento diverso sob a "etiqueta" de ato infracional para os fins da Lei 8.069/1990.

Mas, como a conduta é necessariamente considerada criminosa, sob pena de não poder o menor responder pela prática de ato infracional, soa evidente para este Juízo que a sua prática é suficiente para configuração do óbice "não se dedique às atividades criminosas", previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

No mesmo sentido:

TRF4-) PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando demonstrado que o réu praticou diversos atos infracionais, os quais, embora não configurem reincidência ou Maus antecedentes, revelam a dedicação a atividades criminosas, restando ausente um dos requisitos legais necessários à aplicação da referida minorante. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que, conquanto o réu não ostente antecedentes criminais, nem haja prova de que integre organização criminosa, a não aplicação da causa de redução de pena foi fundamentada na existência de mais de 10 (dez) processos instaurados, os quais revelam o histórico de atos infracionais do acusado (estupro, roubo, furto, receptação, lesões corporais, ameaça, tentativa de homicídio e delitos de trânsito), restando evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas e, consequentemente, o óbice expressamente previsto na norma legal. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5000509-04.2014.404.7210, 4ª Seção do TRF da 4ª Região, Rel. Márcio Antônio Rocha. j. 16.07.2015, maioria, DE 21.07.2015).

E ainda: Apelação Criminal nº 5004789-63.2014.404.7001/PR, 8ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Simone Barbisan Fortes. j. 30.07.2014, maioria, DE 13.08.2014; Apelação nº 0008236-84.2011.8.08.0024 (024110082369), 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Ney Batista Coutinho. j. 27.03.2013, unânime, DJ 05.04.2013.

Por sua correção, merece ser prestigiado o ENUNCIADO Nº 32 do FONAJUC: Havendo registro de ato infracional praticado pelo réu, a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 poderá ser afastada.

O eminente Desembargador Relator do HC 2001547-75.2022.8.26.0000 asseverou nas pgs. 150: "Contudo, embora o registro de atos infracionais pretéritos de fato consista

em elemento aceito para se concluir pela habitualidade delitiva" (destaque do Juízo), a indicar que embora o réu pudesse responder o processo em liberdade, poderia não fazer jus à minorante que fica condicionada à ausência de dedicação a atividades criminosas ou seja, inexistência de habitualidade na traficância.

À míngua de causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena, torno em definitiva a pena supra.

Mantido o caráter hediondo da conduta, o regime inicial é o FECHADO, único capaz de romper a teia criminosa em que o réu encontra-se envolvido, afastando-o do contado com sua "clientela" ou fornecedores de maior envergadura.

Permito ao réu que recorra em liberdade, diante da decisão de pgs. 130/155 emanada da Instância Superior.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Ressalte-se que o réu está patrocinado por advogada dativa e relatou que não possui emprego. Assim, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Fica suspensa a cobrança na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c/c art. 3º do CPP.

Honorários da advogada dativa na forma do convênio OAB-DPE. Expeça-se certidão, na ordem regular dos serviços.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão, observando o regime fixado e a necessidade de apresentação do réu para regular audiência de custódia;
Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.
Publique-se,
Intime-se e
Cumpra-se.

Sao Jose do Rio Pardo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA